

Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Deutschland

Christian Starck*

I. Vorgeschichte.....	271
II. Neuanfang in Deutschland 1949.....	273
III. Uminterpretation und Verfassungsergänzung	274
IV. Gleichberechtigung (Satz 1) und tatsächliche Durchsetzung (Satz 2)	275
V. Einzelne Rechtsgebiete.....	281
VI. Differenzierungserlaubnisse	284
VII. Abschließende Bemerkungen.....	285

I. Vorgeschichte

Die Gleichberechtigung von Männern und Frauen hat sich erst seit Beginn des 20. Jahrhundert und nur allmählich durchgesetzt. Frauen standen früher unter der Vormundschaft des Vaters, nach ihrer Eheschließung ihres Ehemannes. Konsequenterweise hatten sie kein Wahlrecht. Das allgemeine Wahlrecht, das in der Verfassung der Frankfurter Paulskirche (1849) vorgesehen war und unter der Geltung der deutschen Reichsverfassung von 1871 eingeführt wurde, war Männerwahlrecht. Zur damaligen Zeit hatten in keinem Staat der Welt Frauen das Wahlrecht. Kant hatte in der Metaphysik der Sitten 1797 (Rechtslehre, Staatsrecht § 46) geschrieben, dass „alles Frauenzimmer“ (damit sind alle Frauen gemeint) als passive Staatsbürger vom Wahlrecht ausgeschlossen sei.

* Professor für öffentliches Recht an der Georg-August-Universität Göttingen.
Online: <http://publication.iias.sinica.edu.tw/32318012.pdf>;
<http://publication.iias.sinica.edu.tw/32418012.pdf> (Chinese version).



Sieht man sich Tabellen über die Einführung des Frauenwahlrechts in den verschiedenen Staaten an, so zeigt sich, dass Neuseeland das erste Land war, das 1893 dauerhaft das Frauenwahlrecht einführte. Es folgten Finnland (1906), Australien (nur weiße Frauen, 1908), Norwegen (1913), Island (1915), Dänemark und Österreich (1918). Die Weimarer Reichsverfassung (1919) brachte für Deutschland das Frauenwahlrecht, auch Niederlande und Polen (1919). Danach folgten USA (1920), Schweden (1921), Großbritannien (1928), Brasilien (1932), Frankreich (1945), Italien (1946), Chile (1949), die Schweiz (1971), Portugal (1974), Liechtenstein 1984 (eine Liste aller Staaten im Internet).

Die Klausel des Art. 109 Abs. 2 WRV, aus der sich das Wahlrecht der Frauen ergibt, lautet: „**Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.**“ Im maßgebenden Kommentar zur Weimarer Reichsverfassung von *Gerhard Anschütz* heißt es dazu:¹ „Abs. 2 verkündet die Gleichberechtigung der Frauen mit den Männern. Diese Gleichberechtigung erstreckt sich jedoch nur auf den Kreis der *staatsbürgerlichen* Rechte und Pflichten (d.h. derjenigen Rechte und Pflichten, die ein organschaftliches Handeln oder persönliche Dienstleistungen für den Staat zum Gegenstand haben), und auch hier gilt sie nicht unbeschränkt, sondern nur ‚*grundsätzlich*‘, d.h. unter Vorbehalt aller Reichs- und Landesgesetze, welche Ausnahmen von dem Grundsatz vorschreiben oder zulassen.“ Anschütz weist dann darauf hin,² dass sich Abs. 2 nicht auf privatrechtliche Verhältnisse beziehe; ein Antrag in der verfassungsgebenden Nationalversammlung, welcher ihn auf dieses Gebiet ausdehnen wollte, sei abgelehnt worden. So seien auch die Vorrechte des Ehemannes gegenüber der Ehefrau im Familienrecht von dem Prinzip des Art. 109 Abs. 2 unberührt geblieben.

¹ *Gerhard Anschütz*, Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919, 14. Aufl., 1933, S. 529 (Hervorhebung im Original).

² *Anschütz* (Fn. 1), S. 530.

II. Neuanfang in Deutschland 1949

Mit dem Grundgesetz ist 1949 ein Neuanfang gemacht worden. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG lautet: „**Männer und Frauen sind gleichberechtigt.**“ Damit erweitert das Grundgesetz den Art. 109 Abs. 2 WRV, wo nur von den staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten die Rede war. Da die vielen Ungleichbehandlungen besonders im Familienrecht, im Staatsangehörigkeitsrecht, im Internationalen Privatrecht, im Arbeitsrecht und im Sozialversicherungsrecht neue gesetzliche Vorschriften erforderten, war in Art. 117 Abs. 1 GG geregelt worden, dass dem Art. 3 Abs. 2 entgegenstehendes Recht bis zu seiner Anpassung an diese Bestimmung in Kraft bleibt, jedoch nicht länger als bis zum 31. März 1953. Diese Regelung war notwendig, da die Grundrechte gemäß Art. 1 Abs. 3 GG unmittelbar galten, das Zivilrecht und andere Gesetze aber erst gesetzgeberisch umgeformt werden mussten. Neu geschaffenes Recht musste allerdings dem Art. 3 Abs. 2 von Anfang an entsprechen. Nach dem 31. März 1953 war nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Dezember 1953³ das dem Art. 3 Abs. 2 GG widersprechende Recht durch richterliche Auslegung anzupassen. Der Gesetzgeber zog zumeist erst nach solchen richterlichen Anpassungen im Zivilrecht, im internationalen Privatrecht, im Staatsangehörigkeitsrecht und in anderen Rechtsgebieten nach.

Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG *gebietet* Gleichberechtigung von Männern und Frauen; Art. 3 Abs. 3 *verbietet* Benachteiligung oder Bevorzugung u.a. wegen des Geschlechts. Gebotsnorm und Verbotsnorm haben denselben Inhalt. Die Doppelung der Norm erklärt sich aus ihrer Entstehungsgeschichte. Die besondere Regelung der Gleichberechtigung in Art. 3 Abs. 2 GG macht den Unterschied zu Art. 109 Abs. 2 WRV deutlich. Art. 3 Abs. 3 bringt das Differenzierungsverbot besser zum Ausdruck und hat somit klarstellende Funktion.

³ BVerfGE 3, 225 (225).

III. Uminterpretation und Verfassungsergänzung

In den 1980er Jahren ist in der juristischen Literatur versucht worden, Art. 3 Abs. 2 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 Satz 1 GG) als Auftrag zur faktischen Gleichstellung von Männern und Frauen zu interpretieren, ja sogar die Forderung nach faktischer Geschlechterparität daraus abzuleiten. Das Bundesverfassungsgericht hat 1987 solche Gedanken über faktische Gleichstellung erörtert, aber offen gelassen, ob der Gesetzgeber „aus Art. 3 Abs. 2 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip verpflichtet sein könnte, die Voraussetzungen für eine faktische Gleichberechtigung (sic!) zwischen Männern und Frauen zu schaffen“⁴. Fünf Jahre später hat das Bundesverfassungsgericht, Verfassungs- und Rechtspolitik antreibend, obiter dictum zum Verhältnis der Abs. 2 und 3 des Art. 3 folgendes ausgeführt:⁵ „Der über das Diskriminierungsverbot des Art. 3 Abs. 3 hinausgehende Regelungsgehalt von Art. 3 Abs. 2 GG besteht darin, dass er ein Gleichberechtigungsgebot aufstellt und dieses auch auf die gesellschaftliche Wirklichkeit erstreckt.“ Diese Vorschrift ziele auf die Angleichung der Lebensverhältnisse. Faktische Nachteile, die typischerweise Frauen träfen, dürften wegen des Gleichberechtigungsgebots des Art. 3 Abs. 2 durch begünstigende Regelungen ausgeglichen werden. Diese politisch motivierte, vom Zeitgeist getriebene erweiternde Auslegung des Art. 3 Abs. 2 in seiner ursprünglichen Fassung ist inzwischen überholt, nachdem diese Vorschrift durch Verfassungsänderung vom 27. Oktober 1994 durch folgenden zweiten Satz ergänzt worden ist: **„Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“**

⁴ BVerfGE 74, 163 (179 f.).

⁵ BVerfGE 85, 191 (206 f.) und wiederholend, ebenfalls nicht entscheidungsrelevant BVerfGE 89, 276 (285); BVerfGE 92, 91 (109).

IV. Gleichberechtigung (Satz 1) und tatsächliche Durchsetzung (Satz 2)

Die soeben zitierte Ergänzung des Art. 3 Abs. 2 normiert ein Staatsziel, durch das die zuständigen staatlichen Organe angehalten werden, Maßnahmen zur Angleichung der Lebensverhältnisse von Männern und Frauen zu ergreifen, indem (1) die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern gefördert und (2) auf die Beseitigung bestehender Nachteile hingewirkt wird. Während Abs. 2 Satz 1 mit „Männer“ und „Frauen“ die einzelnen Individuen schützt und sie mit subjektiven Rechten ausstattet, meint Abs. 2 Satz 2 mit „Frauen und Männern“ ebenfalls die Individuen, aber durchaus in Relation zu den Geschlechtergruppen, wie sie sich in der gesellschaftlichen Wirklichkeit darstellen.⁶

Nach der Begründung der Gemeinsamen Verfassungskommission, die 1993 den Entwurf unterbreitet hat, handelt es sich weniger um den Versuch der Lösung eines rechtlichen als eines gesellschaftlichen Problems.⁷ Es gehe darum, „eine faktische Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern zu erreichen“. Die Formulierung als Staatsziel mache deutlich, „dass kein Individualanspruch auf ein bestimmtes staatliches Handeln eingeräumt werden soll.“ Der Gesetzgeber kann deshalb im Rahmen seines Gestaltungsermessens entscheiden, wie er dem Gebot des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 nachkommt,⁸ wie das Bundesverfassungsgericht 2003 entschieden hat. Die Kommission war sich darin einig, dass Frauenförderung durch starre Quoten nicht gestattet sei. Offen blieb in den Beratungen jedoch, ob andere Formen bevorzugender Ungleichbehandlung zur Förderung von Frauen erlaubt seien, insbesondere ob

⁶ Im Folgenden greife ich zum Teil wörtlich zurück auf meine Ausführungen in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Bd. I, 6. Aufl., 2010, Art. 3 Rn. 309-318.

⁷ BT-Drs. 12/6000, S. 50, auch zum Folgenden.

⁸ BVerfGE 109, 64 (90); *Lerke Osterloh*, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, 7. Aufl., 2014, Art. 3 Rn. 262: Keine subjektiven Rechte, insbesondere keine originären Teilhabe- bzw. Leistungsansprüche.

bei gleicher Eignung und Befähigung Frauen Männern so lange vorgezogen werden dürfen, wie die Gruppe der Frauen im jeweiligen Bereich unterrepräsentiert sei. Dies ist nun durch Verfassungsinterpretation zu klären.

Staatsziele werden unter Beachtung der Grenzen verwirklicht, die die Verfassung durch Kompetenzregeln, Grundrechte und sonstige Bestimmungen zieht. So hat das Bundesverfassungsgericht zutreffend formuliert, dass das im Sozialstaatsprinzip enthaltene soziale Staatsziel nur in den Grenzen der Rechtsstaatlichkeit verwirklicht werden dürfe.⁹ Entsprechendes gilt für das neue, verfassungsrechtlich verankerte Staatsziel des Art. 3 Abs. 2 Satz 2. Bei der Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern muss das strikte Differenzierungsverbot des ersten Satzes des Abs. 2 und des Abs. 3 Satz 1 bezüglich des Geschlechts, das heißt das individuelle Recht auf Gleichbehandlung beachtet werden. So ist z.B. beim Zugang zu öffentlichen Ämtern eine leistungsbezogene Quotenregelung dergestalt, dass bei Bewerbern mit gleicher Leistung Frauen so lange bevorzugt werden müssen, bis die gesetzlich vorgeschriebene Quote erfüllt ist, verfassungswidrig, weil das Geschlecht nach Art. 33 Abs. 2 GG kein erlaubtes Differenzierungskriterium für den Zugang zu öffentlichen Ämtern ist und weil das Geschlecht nach Art. 3 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 als Auswahlkriterium ausdrücklich verboten ist.¹⁰

Deshalb sind Interpretationsansätze verfehlt, die das Staatsziel des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 auf die grundrechtliche Ebene der strikten Differenzierungsverbote bezüglich des Geschlechts heben und mit der Zauberformel von der „praktischen Konkordanz“ eine Einschränkung des strikten Differenzierungsverbotes

⁹ BVerfGE 88, 203 (319).

¹⁰ OVG Lüneburg, DVBl 1995, S. 1254 (1256 f.); *Hans-Werner Laubinger*, Die »Frauenquote« im öffentlichen Dienst — Teil I, VerwArch 87 (1996), S. 305 (473, 510 ff., 527 ff.) mit umfassenden Nachweisen; *Wolfgang Rüfner*, in: Wolfgang/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 1996, Art. 3 Abs. 2 und Abs. 3 Rn. 767 ff.; *Günter Dürig/Rupert Scholz*, in: Maunz/Dürig (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. I, Stand: Lfg. 32 Oktober, Art. 3 Abs. 2 Rn. 61 ff.

begründen,¹¹ als wenn es sich um die Einschränkung eines Freiheitsrechts zur Sicherung der Freiheit anderer handelte. So wird geprüft, ob die Einschränkung des strikten Gleichberechtigungsgebots geeignet, erforderlich und verhältnismäßig zur Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung sei. Damit wird die rechtsdogmatische Struktur der strikten Differenzierungsverbote des Art. 3 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 verkannt. Von einem strikten Differenzierungsverbot, wie es die Garantie der Gleichberechtigung von Männern und Frauen darstellt, darf nicht zugunsten der Verwirklichung von Staatszielen abgewichen werden. Differenzierungen sind nur erlaubt, soweit sie den Schutz der Frau aufgrund ihrer biologisch-geschlechtlichen Andersartigkeit dienen oder unabhängig davon verfassungsrechtlich unmittelbar angeordnet sind. Darauf komme ich noch zurück. Im Übrigen sind Staatsziele unter Beachtung der subjektiven Individualrechte zu verwirklichen. Während sich der normative Inhalt des allgemeinen Gleichheitssatzes erst aus dem verfassungsrechtlichen Kontext erschließt, zu dem auch die verfassungsrechtlichen Staatsziele gehören, stehen die speziellen Differenzierungsverbote der Art. 3 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1 nicht unter dem Vorbehalt von Staatszielen.¹²

Dieses Auslegungsergebnis stimmt mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) überein, der in mehreren Entscheidungen leistungsbezogene Quoten für unvereinbar hält mit der Richtlinie des Rates vom 9. 2. 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen.¹³ Im ersten Urteil (Kalanke 1995) hat der EuGH gegen das

¹¹ Vgl. zu diesem Vorgehen *Ingwer Ebsen*, Gleichberechtigung von Männern und Frauen, in: Benda/Maihofer/Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, Bd. I, 2. Aufl., 1994, § 8 Rn. 42 ff.

¹² *Udo Di Fabio*, Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, AöR 1997, S. 404 (443).

¹³ Richtlinie 76/207 EWG; EuGH, Urteil v. 17.10.1995 — Rs. C-450/93 (Kalanke/Bremen) = JZ 1996, S. 196 f. mit Anm. *Christian Starck*.

Bremische Gleichstellungsgesetz entschieden, dass Rechtsgleichheit beim Zugang zum Öffentlichen Dienst individualrechtlich zu verstehen sei und hat damit jedem Gleichheitsverständnis eine Absage erteilt, nach dem das Kollektiv der Frauen dem Kollektiv der Männer gegenübersteht. An die Stelle der Chancengleichheit die Gleichheit des Ergebnisses zusetzen, betrachtet der EuGH als Verstoß gegen das in der Richtlinie verankerte individuelle Recht auf Gleichbehandlung.¹⁴

Weitere Urteile des EuGH zur Frauenförderung durch die nordrhein-westfälische und hessische Gesetzgebung legen starre Quoten so aus, dass sie weich werden.¹⁵ Der EuGH unterscheidet zwischen Förderung der Chancengleichheit, die er für vereinbar hält mit dem individuellen Recht auf Gleichbehandlung, und der Herstellung von Ergebnisgleichheit, die mit diesem Recht unvereinbar ist. Aus den EuGH-Urteilen ergibt sich eindeutig, dass allein das Kriterium „weibliches Geschlecht“ bei einer Beförderung nie ausschlaggebend sein darf. Gleichqualifizierten männlichen Bewerbern muss in jedem Einzelfall eine objektive Beurteilung garantiert sein. Dabei müssen alle die Person der Bewerber betreffenden Kriterien berücksichtigt werden. Der den weiblichen Bewerbern eingeräumte Vorrang entfällt, wenn eines oder mehrere dieser Kriterien zugunsten des männlichen Bewerbers überwiegen. Solche Kriterien dürfen allerdings gegenüber weiblichen Bewerbern keine diskriminierenden Wirkung haben. So ist nach Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie die Berücksichtigung des Ehe- und Familienstandes unzulässig. Ein verheirateter

¹⁴ S. EuGH, Urteil v. 17.10.1995 — Rs. C-450/93, JZ 1996, S. 197 Rn. 23. — Kalanke/Bremen.

¹⁵ EuGH, Urteil v. 11.11.1997 — Rs. C-409/95 (Marschall./ Land Nordrhein-Westfalen) = JZ 1998, S. 19 f. mit Anm. *Christian Starck*; EuGH, Urteil v. 28.3.2000 — Rs. C-158/97 (Badeck u.a./ Hess. Ministerpräsident) = JZ 2000, S. 667 f. mit Anm. *Christian Starck*. Zur Notwendigkeit einer europarechtskonformen Interpretation des Art. 3 Abs 2 GG vgl. *Claus Dieter Classen*, Wie viele Wege führen zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen? Gemeinsamkeiten und Unterschiede von deutschem und europäischem Recht, JZ 1996, S. 921 (930). Quoten halten auch für unzulässig z. B. *Jörn Ipsen*, Staatsrecht II, 16. Aufl., 2013, Rn. 822 ff.; *Di Fabio* (Fn. 12), S. 441 ff.; OVG Münster, NVwZ 1996, S. 494 f.

Bewerber mit Kindern und nichtverdienender Ehefrau darf also einer ledigen Bewerberin oder einer Bewerberin mit verdienendem Ehemann nicht vorgezogen werden. Insgesamt kann festgehalten werden, dass es der EuGH ablehnt, die Chancengleichheit der Frauen durch Diskriminierung der Männer zu bewirken. Insoweit ist jegliche Frauenquote zur Sicherung der Ergebniseinheit ebenso wenig mit dem EU-Recht wie mit dem deutschen Verfassungsrecht vereinbar.¹⁶

Staatliche Maßnahmen zur Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung der Frauen mit den Männern müssen also ihrerseits mit den Grundrechten einschließlich Art. 3 Abs. 2 Satz 1 im Einklang stehen, auf den sich Männer ebenso berufen können wie Frauen. Das verfassungsrechtliche Problem besteht darin, Regelungen zu erlassen, die die Chancengleichheit der Frauen sichern, aber im Ergebnis das Recht der einzelnen Männer auf Gleichberechtigung nicht verletzen. Die Frage kann nicht pauschal, sondern nur für die einzelnen Regelungen am Maßstab der einschlägigen Verfassungsnormen beantwortet werden.¹⁷ Eine gesetzliche Pflicht, eine bestimmte Quote Frauen anzustellen, würde gegen die Vertragsfreiheit oder gegen die verfassungsrechtliche Regelung über den Zugang zu öffentlichen Ämtern verstoßen.

Die in Art. 12 a GG eröffnete Möglichkeit, Männer der Wehrpflicht zu unterwerfen, schließt eine entsprechende Verpflichtung für Frauen aus.¹⁸ Dies ist ein spezielles verfassungsrechtliches Differenzierungsgebot, das als Ausnahme dem Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG vorgeht. Frauen können demnach nur auf freiwilliger Basis in den Wehrdienst aufgenommen werden. Im Verteidigungsfall können Frauen unter besonderen Voraussetzungen zum zivilen

¹⁶ *Werner Heun*, in: *Dreier (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar*, Bd. I, 3. Aufl., 2013, Art. 3 Rn. 113, will aber flexible Quoten zulassen, die keine zwingende, automatische Bevorzugung für Frauen vorsehen.

¹⁷ *Hans-Joachim Mengel*, Maßnahmen „Positiver Diskriminierung“ und Grundgesetz, *JZ* 1982, S. 530 (535).

¹⁸ *BVerfGE* 48, 127 (165).

Sanitätsdienst und zum ortsfesten militärischen Lazarettendienst herangezogen werden. Sie dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden (Art. 12 a Abs. 4 Satz 2 GG). Ob diese Unterscheidung auf biologischen Unterschied gestützt werden kann, was zu verneinen ist, ist belanglos, da die Verfassung selbst auch ohne solche Gründe Ausnahmen von Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG machen kann.

Die Chancengleichheit, das heißt die Ausgangslage der Frauen, kann dadurch verbessert und kompensatorisch der Situation der Männer angeglichen werden, dass im Öffentlichen Dienst z.B. Geburten und Erziehungsjahre angerechnet werden. Geburten beruhen auf biologischem Unterschied. Erziehungszeiten werden nicht geschlechtsspezifisch, sondern sozialgesellschaftlich in der Regel von Frauen wahrgenommen und können deshalb rechtlich als geschlechtsneutral formuliertes Kriterium herangezogen werden, das faktisch zugunsten von Frauen wirkt. Andere Mittel zur Förderung der Chancengleichheit sind: Flexible familiengerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen und Arbeitszeit, wozu auch Halbtagsarbeit gehört, sowie die Förderung der beruflichen Wiedereingliederung von Frauen nach Geburt und (geschlechtsneutral formuliert) nach Kindererziehung. Aber auch organisatorische Maßnahmen kommen in Betracht, wie Frauenbeauftragte, Berichte usw.¹⁹ Die Frauen müssen sich, auch wenn sie in vielen Bereichen des Öffentlichen Dienstes noch unterrepräsentiert sind, den Zugangsvoraussetzungen in Konkurrenz mit den Männern stellen. Erst im Laufe der Zeit wird eine weitgehende faktische Gleichstellung von Männern und Frauen eintreten, die für die Lehrerberufe im Beamtenstand bereits zugunsten der Frauen ausgeschlagen ist.

Der durch das Staatsziel des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 zum Ausdruck gebrachte

¹⁹ Aus der umfangreichen Literatur s. vor allem *Ursula Köbl*, Welche Maßnahmen empfehlen sich, um die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie zu verbessern?, JZ 1994, S. 840 (843 ff.); *Ulrike Bumke*, Art. 3 GG in der aktuellen Verfassungsreformdiskussion: zur ergänzenden Änderung des Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, Der Staat 32 (1993), S. 117 (124 f.); *Laubinger* (Fn. 10), S. 473, 532 f.; *Osterloh* (Fn. 8), Art. 3 Rn. 282.

Auftrag, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung zu fördern, rechtfertigt es z.B., Frauen bei der Förderung selbständiger Betriebsgründungen im Handwerk durch Subventionen günstigere Bedingungen einzuräumen, als Männern. Frauen wurde eine Frist von fünf Jahren nach Bestehen der Meisterprüfung für eine Betriebsgründung eingeräumt, Männern dagegen nur eine Frist von zwei Jahren. Damit werden – pauschal betrachtet - vor allem berufliche Nachteile der Frauen in der Zeit der Familiengründung ausgeglichen.²⁰

V. Einzelne Rechtsgebiete

Beruf und Ausbildung: Das Bundesverwaltungsgericht hatte die Sperre des Berufs der Hebamme für Männer als verfassungsrechtlich zulässig angesehen, solange nicht bis zur Evidenz feststehe, dass die Schwangeren in aller Regel keinen inneren Vorbehalt mehr gegen männliche Hebammen hätten.²¹ Das Gericht hatte seine Argumentation darauf gestützt, dass eine Schwangere in der Regel nicht die Hebamme wählen könne, sondern auf den Dienstplan angewiesen sei, den das Krankenhaus für seine Hebammen festgelegt habe. Dieser Gesichtspunkt ist nicht von der Hand zu weisen. Da die Intimsphäre der Frau berührt wird, darf sie in Krankenhäusern nicht gezwungen werden, von einer männlichen Hebamme versorgt zu werden. Gleichwohl darf Männern wegen Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG der Zugang zum Beruf der Hebamme nicht versagt werden;²² sie müssen sich freilich gefallen lassen, im Einzelfall abgelehnt zu werden, und die Krankenhäuser, die männliche Hebammen angestellt haben, dürfen auf Schwangere keinen Zwang ausüben, sich von einer männlichen Hebamme versorgen zu lassen. Der Gesetzgeber hat den „Entbindungspfleger“ ins Gesetz aufgenommen.²³

²⁰ BVerwG, DVBl. 2003, S. 139 (141).

²¹ BVerwGE 40, 17 (21 f.).

²² EuGH, Urteil v. 08.11.1983 — Rs. 165/82 = NJW 1985, S. 539 f.

²³ Gesetz vom 4. 6. 1985 (BGBl. I 1985, S. 102).

Beamtenrecht: Die Teilzeitbeschäftigung ist ein Fremdkörper im deutschen Beamtenrecht. Denn die Vollzeitbeschäftigung auf Lebenszeit ist seit jeher das Leitbild und der wesentliche Strukturinhalt des Beamtenverhältnisses.²⁴ Die Teilzeitbeschäftigung ist durch Gesetzesänderung eingeführt worden, um insbesondere Frauen, die Kinder erziehen, den Zugang zum Beamtenverhältnis zu eröffnen. Zunächst war der Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung wegen Betreuung von Kindern bis zum 16. Lebensjahr als Frauenförderungsmaßnahme auf Mütter beschränkt. Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG verbietet jedoch die Ungleichbehandlung von Müttern und Vätern; vielmehr muss alternativ auch der Vater von diesem Anspruch Gebrauch machen können. Das ist jetzt in den Gesetzen durch geschlechtsneutrale Formulierung sicher gestellt. Der Staat ist aber nicht verpflichtet, beiden Eltern gleichzeitig die Teilzeitbeschäftigung zu gewähren.

Ehe- und Familienrecht: Eine gesetzliche Regelung, dass der Ehe- und Familienname einheitlich ist, stünde im Einklang mit Art. 3 Abs. 2 GG, da der einheitliche Name die Zugehörigkeit zu einer Familie offenkundig macht.²⁵ Die bis 1976 geltende traditionelle Regel, dass der Ehe- und Familienname der Name des Mannes ist, war mit Art. 3 Abs. 2 nicht vereinbar, da weder biologische Unterschiede noch Gründe des Schutzes von Ehe und Familie die Bevorzugung des Mannesnamens rechtfertigen konnten. D. h. alle Ehen, die seit dem 1. 4. 1953 (vgl. Art. 117 Abs. 1 GG) geschlossen worden sind, waren einem verfassungswidrigen Namensrecht unterworfen. Ob daraus freilich zwingend eine Übergangsregelung für alle nach dem 1. 4. 1953 geschlossenen Ehen abgeleitet werden konnte, nach der die Ehegatten berechtigt sind, ihren Ehenamen zu wechseln, erscheint zweifelhaft.²⁶ Denn die fortdauernde Identität des einmal — wenn auch durch eine verfassungswidrige Beschränkung — festgelegten Namens ist ein hoher Wert in sich. Das später festgelegte

²⁴ BVerfGE 71, 39 (59 f.).

²⁵ BVerfGE 17, 168 (171); BVerfGE 78, 38 (49).

²⁶ BVerfGE 48, 327 (340).

Wahlrecht zwischen dem Geburtsnamen des Mannes und dem der Frau entsprach dem Art. 3 Abs. 2 GG. Die gesetzliche Entscheidung für den Mannesnamen, falls keine Bestimmung getroffen wird, entsprach zwar der überwiegenden Praxis der ehelichen Namensgebung, fand aber nicht die Zustimmung des Bundesverfassungsgerichts, das darin eine verfassungswidrige Bevorzugung des Mannes sah, die auf das Wahlrecht der Ehegatten zurückwirke und damit die Frau benachteilige.²⁷ Diese Entscheidung führte in Deutschland zur Auflösung des einheitlichen Familiennamens, wenn sich die Eheleute nicht einigen können oder bewusst nicht wollen.

Arbeitsrecht: Im Arbeitsrecht entstehen Gleichberechtigungsprobleme bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses, bei den Arbeitsbedingungen, den Aufstiegschancen und bei der Entlohnung, zu der hier einige Ausführungen erforderlich sind. Die europarechtliche Anordnung, dass jeder Mitgliedstaat die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicherstellt (Art. 157 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union — AEUV), ist eine legitime Einschränkung der Vertragsfreiheit, weil sie aus Art. 3 Abs. 2 GG folgt. Das Hauptproblem bei der rechtlichen Verbürgung der Lohngleichheit besteht darin, dass die Arbeit, die häufig von Frauen geleistet wird, gemessen an typisch männlicher Arbeit, gerecht bewertet wird. Soweit Männer und Frauen die gleiche Arbeit leisten, tauchen keine Probleme auf. Soweit Frauen in sogenannten Leichtlohngruppen eingestuft sind, kann dies — sachlich begründet — auch daran liegen, dass die dort Arbeitenden eine weniger qualifizierte Ausbildung haben oder weniger Beschäftigungsjahre aufweisen können.²⁸ Die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hat seit den 70er Jahren dafür gesorgt, dass das zum Lohn gesagte auch für Zulagen, Versorgungsansprüche, für das Eintrittsalter und die

²⁷ BVerfGE 84, 9 (20).

²⁸ Dazu ausführlich *Manfred Löwisch*, Gutachten für den 50. Deutschen Juristentag, Teilgutachten Arbeitsrecht. Zum Thema: Welche rechtlichen Maßnahmen sind vordringlich, um die tatsächliche Gleichstellung der Frauen mit den Männern im Arbeitsleben zu gewährleisten?, in: Gutachten D zum 50. Deutschen Juristentag, 1974, S. 11 (71 ff.).

Dauer der Beschäftigung und alle Vergünstigungen gilt.

VI. Differenzierungserlaubnisse

Die speziellen Differenzierungsverbote des Art. 3 Abs. 2, 3 erlauben ausnahmsweise Differenzierungen, wovon einige schon genannt worden sind. Die Rechtsgleichheitsgarantie (Art. 3 Abs. 2 Satz 1 GG) darf nicht zum Nachteil der Frau angewandt werden, soweit es um deren Schutz geht, der an die biologisch-geschlechtlichen Besonderheiten der Frau anknüpft. Das Differenzierungsverbot gilt nicht im Hinblick auf Sachverhalte, die nur bei der Frau verwirklicht werden können, wie Schwangerschaft, Gebären, Stillen. Hingegen können nicht aus einer angeblich schwächeren körperlichen Konstitution der Frau allgemeine rechtliche Folgerungen gezogen werden. Die Andersartigkeit der Frau muss einen konkreten Bezug zum geregelten Sachverhalt haben. So sei ein Nachtarbeitsverbot für Frauen unvereinbar mit der Rechtsgleichheit, da arbeitsmedizinische Untersuchungen ergeben hätten, dass Frauen aufgrund ihres Geschlechts durch Nachtarbeit nicht stärker beeinträchtigt würden als Männer. Das Argument, dass Frauen durch Nachtarbeit stärker beeinträchtigt werden wegen ihrer zusätzlichen Belastung durch Hausarbeit und Kindererziehung ließ das Bundesverfassungsgericht nicht gelten, da es nicht geschlechtsspezifisch, sondern rollenspezifisch begründet sei.²⁹ Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit stehen unter dem besonderen Schutz der Verfassung in Art. 6 Abs. 4 GG (jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft) und erlauben Differenzierungen. Ein Minimum an Schutz ist sogar geboten (Differenzierungsgebot des Art. 6 Abs. 4 GG). Schutzvorschriften müssen so gestaltet werden, dass sie sich nicht faktisch diskriminierend auswirken, z.B. für die Einstellungs Voraussetzungen von Frauen im gebärfähigen Alter.

²⁹ BVerfGE 85, 191 (210).

VII. Abschließende Bemerkungen

Die kurze Darstellung der Entwicklung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen, seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, in Deutschland seit 1919, zeigt deutliche Stufen: 1919 grundsätzlich gleiche staatsbürgerliche Rechte, 1949 allgemeine Gleichberechtigung, 1994 Staatsziel „fördern“. Insgesamt möchte ich das Ergebnis dieser Entwicklung als eine Errungenschaft der Rechtskultur bezeichnen. Diese würde allerdings durch rechtlich vorgeschriebene Quoten gestört. Quoten zur Herstellung faktischer Gleichheit sind freiheitsfeindlich. Im Rahmen der grundrechtlich garantierten Freiheit der Ausbildung, der Berufswahl (Art. 12 Abs. 1 GG) und fairer Auswahlverfahren (Art. 3, 33 Abs. 2 GG) und des Staatsziels des Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG wird die geschilderte Errungenschaft voll zur Geltung kommen.

Literaturverzeichnis

- Anschütz, Gerhard (1993), Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919 (1926), Bad Homburg: Gehlen.
- Bumke, Ulrike (1993), Art. 3 GG in der aktuellen Verfassungsreformdiskussion: zur ergänzenden Änderung des Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, Der Staat 32, S. 117-139.
- Classen, Claus Dieter (1996), Wie viele Wege führen zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen? Gemeinsamkeiten und Unterschiede von deutschem und europäischem Recht, JZ, S. 921-930.
- Di Fabio, Udo (1997), Die Gleichberechtigung von Mann und Frau, AöR, S. 404-443.
- Dürig, Günter/Scholz, Rupert (1996), in: Maunz/Dürig (Hrsg.), Grundgesetz, Bd. I, Stand: Lfg. 32 Oktober, München: C. H. Beck, Art. 3 Abs. 2.
- Ebsen, Ingwer (1994), Gleichberechtigung von Männern und Frauen, in: Benda/Maihofer/Vogel (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, Bd. I (1983), 2. Aufl., Berlin: de Gruyter, S. 263-291.
- Heun, Werner (2013), in: Dreier (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, Bd. I, 3. Aufl., Tübingen: Mohr Siebeck, Art. 3.
- Ipsen, Jörn (2013), Staatsrecht II, 16. Aufl., München: Vahlen.
- Köbl, Ursula (1994), Welche Maßnahmen empfehlen sich, um die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Familie zu verbessern?, JZ, 840-851.
- Laubinger, Hans-Werner (1996), Die »Frauenquote« im öffentlichen Dienst — Teil I, VerwArch 87, S. 305-327.
- Löwisch, Manfred (1974), Gutachten für den 50. Deutschen Juristentag. Teilgutachten Arbeitsrecht. Zum Thema: Welche rechtlichen Maßnahmen sind vordringlich, um die tatsächliche Gleichstellung der Frauen mit den Männern im Arbeitsleben zu gewährleisten?, in: Gutachten D zum 50. Deutschen Juristentag, S. 11-104.
- Mengel, Hans-Joachim (1982), Maßnahmen „Positiver Diskriminierung“ und Grundgesetz, JZ, S. 530-538.

- Osterloh, Lerke (2014), in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz Kommentar, 7. Aufl., München: C. H. Beck, Art. 3.
- Rüfner, Wolfgang (1996), in: Wolfgang/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, München: C. F. Müller, Art. 3.
- Starck, Christian (1996), Quotenregelung im Öffentlichen Dienst: Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 17.10.1995 — C-450/93 (Kalanke/Bremen), JZ, S. 197 ff.
- (1998), Die Quotenregelung mit Öffnungsklausel: Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 11. 11. 1997 — Rs. C-409/95 (Marschall../. Land Nordrhein-Westfalen), JZ, S. 139 ff.
- (2000), Zum Hessischen Gleichstellungsgesetz: Anmerkung zum Urteil des EuGH vom 28. 3. 2000 — Rs. C-158/97 (Badeck u.a../. Hess. Ministerpräsident), JZ, S. 667 ff.
- (2010), in: v. Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Bd. I, 6. Aufl., München: Vahlen, Art. 3.

